

الدرس التاسع

المحل و السبب في عقد القرض

المحل في عقد القرض الاستهلاكي:

المفروض أن محل القرض الاستهلاكي هو الفائدة التي تحققها البنوك من عقد القرض أي معدل الفائدة الإجمالي و لكن المرسوم التنفيذي 2015 قصر القرض الاستهلاكي على حالة وحيدة واردة في المادة الأولى منه التي نصت على أن : "..... يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات حصول العائلة على القرض الاستهلاكي الموجهة للسلع ،في إطار إنعاش النشاطات الاقتصادية ."

و لقد أوقف العمل بالقرض الاستهلاكي في سنة 2009 إذ ورد في المادة 75 من قانون المالية رقم 01/09 المؤرخ في 22 يوليو 2009 على ما يلي: "لا يرخص للبنوك منح القروض للأفراد إلا في إطار القروض العقارية."

و أعيد إعمال القرض الاستهلاكي في 2015 و ذلك بمقتضي القانون 10-14 المؤرخ في 2014/12/30 المتضمن قانون المالية لسنة 2015 لاسيما المادة 88 فرخص إذن استثناء الحصول على القرض الاستهلاكي و ذلك لشراء السلع ، و اشترطت المادة 4 من مرسوم 2015 ما يلي:

"المتعاملون الذين تكون منتجاتهم مؤهلة للقرض الاستهلاكي هم الذين:

- يمارسون نشاط انتاج على الاقليم الوطني.
- ينتجون أو يركبون سلعا موجهة للبيع الى الخواص.

يمكن ان تستجيب السلع المؤهلة الى معدل ادماج يحدد عند الحاجة ، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بحماية المستهلك و الوزير المعني ."

و يتضمن قانون حماية المستهلك و المرسوم التنفيذي في تعريفه للقرض الاستهلاكي بأنه يشمل كل بيع لسلعة يكون الدفع فيه على أقساط ، مؤجلا أو مجزأ ، فلم يتضمن المرسوم التنفيذي في المادة الاولى في تعريف القرض الاستهلاكي بيع الخدمة الواردة في المادة الثالثة في قانون حماية المستهلك ،

مما يتطلب استبعاد كل قرض لم يخصص لشراء سلعة كما يستبعد البيع بالتقسيط المباشر أي في الصورة البسيطة الغير مقترن بقرض ، فالمشرع إذن تناول في المرسوم 2015 القرض المخصص للبيع فقط.

فمحل عقد القرض الاستهلاكي وفقا للمرسوم التنفيذي 2015 هو المبيع محل التزام البائع و الثمن محل بيع التزام المشتري و مبلغ القرض و ما تتضمنه من فائدة أي ما يعرف بمعدل الفائدة الاجمالي.

أولا: بالنسبة للمبيع:

فإلى جانب ما تشترطه القواعد العامة يجب أن يتوافر في المبيع شروط المنتج السليم النزيه القابل للتسويق إذ تنص المادة 3 من قانون حماية المستهلك : "يقصد في مفهوم أحكام ما يأتي:

المنتج : كل سلعة أو خدمة يمكن أن يكون موضوع تنازل بمقابل أو مجانا،

منتج سليم و نزيه و قابل للتسويق : منتج خال من أي نقص و/أو عيب خفي يضمن عدم الأضرار بصحة و سلامة المستهلك و/أو مصالحه المادية و المعنوية،

منتج مضمون : كل منتج ، في شروط استعماله أو الممكن توقعها ، بما في ذلك المدة ، لا يشكل أي خطر أو يشكل أخطارا محدودة في أدنى مستوى تتناسب مع استعمال المنتج و تعتبر مقبولة بتوفير مستوى حماية عالية لصحة و سلامة الشخص،

منتج خطير: كل منتج لا يستجيب لمفهوم المنتج المضمون المحدد أعلاه،

فكل منتج لا يتوافر فيه الشروط المطلوبة في الأمن و السلامة يعرض البائع لعقوبة المنصوص عليها في المادة 68 و ما يليها من قانون حماية المستهلك و يمكن توقيع عقوبة جزائية على أساس المادة 429 عقوبات.

ثانيا : بالنسبة للثمن:

لم يتعرض المشرع بنص خاص للثمن كركن في العقد إلا استثناءا بصدد الالتزامات سنتعرض له ضمن الآثار، الى جانب أن القرض المخصص إذا كانت المؤسسة المالية هي التي ستدفع الثمن فهناك دائما جزء يدفعه المشتري،

وهذا لم يتعرض المشرع له إلا ضمن نص المادة 13 من المرسوم 2015 ، و
لاشك أن النصوص العامة تتضمن ضرورة تحديد الثمن كما أنه في حالة أداء
المشتري جزءا من الثمن يجب أن يسلمه البائع مخالصة عن ذلك أو وصل
استلام بالدفع كما نصت المادة 13 الثالثة عشره المذكورة أعلاه.

ثالثا: الفوائد في المؤسسات المالية:

الهدف الأول لمؤسسات القرض و النقد الحصول على فائدة باعتبارها تاجرة و
قد أجاز المشرع في المادة 456 مدني (القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24
ديسمبر 1984) لمؤسسات القرض أخذ فائدة إذ ينص على ما يلي : "يجوز
لمؤسسات القرض التي تمنح قروضا قصد تشجيع النشاط الاقتصادي الوطني
أن تأخذ فائدة يحدد قدرتها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية " .

الفوائد نوعان:

1 : الفوائد التأخيرية : فبمجرد التأخير عن التسديد تترتب نتيجة تأخير في
الآجال تعويض، بمعنى آخر بمجرد التأخر يستحق الدائن الضرر اللاحق من
هذا التأخير.

- المادة 186 مدني : "إذا كان محل الالتزام بين الأفراد مبلغا من النقود عين
مقداره وقت رفع الدعوى و تأخر المدين في الوفاء به ، فيجب عليه أن يعوض
للدائن الضرر اللاحق من هذا التأخير .
فليس بمجرد التأخير يعوض ، فيعوض في حالة وجود ضرر و يكون قائما
حتما.

- فالمشرع الفرنسي و المصري يعتبرون أنه بمجرد التأخير هناك ضرر قائما
حتما فيعوض (كل تأخير حتما فيه ضرر قائم و لكن سقفه محدود بسقف معين
محدد قانونا.)

-أما المشرع الجزائري فقد ربط التعويض عن التأخير بالضرر ، فإن فوائد
التأخير هي ربا النسيئة التي تقرر في مقابل الزمن فقط.

2- الفوائد التعويضية : يري البعض أن الفائدة نتيجة تأجير النقود ، فالأجرة
هي الفائدة و هناك من اعتبرها تعويضا عن مخاطر المديونية (القرض) .

- المشرع غالبا ما يضع سقف أعلى للفوائد.

- البنوك لها الحرية في تحديد الفائدة و تختلف من بنك لآخر.

- البنوك كلها تأخذ فائدة ، في غالب الاحيان يتدخل بنك الجزائر و البنوك لوضع حد أقصى لهذه الفائدة تعتمد على معدل الفائدة الفعلية الإجمالية التي تشمل :

- تكلفة الحصول على الودائع من الموردين.
- تكلفة القيام بالأعمال الإدارية.
- تشمل المصاريف و العمولات.

- المشرع في المرسوم 2015 في المادة 02 ينص على معدل الفائدة الفعلي الإجمالي يعرفه بأنه "المعدل السنوي المعبر عنه بنسبة مئوية و يضم فيها، يخص كل قرض مستوفي الفوائد و المصاريف و الاقتطاعات أو التعويضات المرتبطة بحصول القرض."

- كما أن المشرع فيما يخص العرض المسبق نص عليه في المادة 07 من مرسوم 2015: "يجب ان يبين كل عرض للعقد الاستهلاكي..... و كذلك نسبة الفوائد الإجمالية....."

الفوائد التعويضية : وتنقسم الى:

1. الفوائد البسيطة : المؤسسة المالية تأخذ فائدة معينة محددة كل فترة محددة.
 2. الفوائد المركبة : لا تطلبها البنوك في أول سنة ، تتركها تتراكم و تنتج في ذاتها فوائد و تسمى بالرأسمالة و هي فوائد خطيرة ، أحيانا اذا تراكمت لعدة سنوات فهي تفوق رأس المال (هذه الفوائد) وهذا ما يعرف بالرأسمالة .
 - في فرنسا و ألمانيا ، يمنع أخذ الرأسمالة أو الفوائد المركبة في القروض الاستهلاكية ويجيزونها في غير قروض الاستهلاك فقط و يعتبر أخذ فائدة على متجمد الفوائد ربا بأضعاف مضاعفة .
 3. الفوائد الثابتة : هي فوائد سنوية ثابتة بمعنى البنك يعلن بأنه يأخذ في السنة 7% أو 5%.
 4. الفوائد المتغيرة : وهي تتغير من فترة لأخرى وفقا لبنود التقييس و تكون خاضعة لظروف الاقتصادية حيث تضع المؤسسات المالية مرجع قياسي يمكن أن يتغير.
- هل هو أحسن بالنسبة للشخص ان تكون الفائدة ثابتة أم متغيرة ؟

- عندما تكون قروض قصيرة المدة فالفائدة المتغيرة تكون أحسن و ذلك لأنه بالنسبة للفائدة الثابتة يتغير معدلها من سنة إلى سنة إذاً هناك تأمين لمواجهة مخاطر الفائدة يدفعها المقترض بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

و حماية المستهلك في اطار الفائدة أمر ضروري بل الحماية مطلوبة أيا كانت صفة المقترض فسقف الفائدة الأعلى غير جائز التعامل بما يجاوزه سواء كان الشخص المتعاقد مستهلك أم محترف لأن ذلك مرتبط بمديونية قد تؤدي الى مشاكل اجتماعية و خيمة بل و اقتصادية أيضا فسبب الأزمة المالية العالمية 2008 هي القروض الممنوحة التي واجهها غالبية المقترضين في تسديدها لهذا فتحدد سقف أعلى و مراقبته حتمية تلجأ اليه كل التشريعات.

الفرق بين الفائدة والربا

فيلاحظ أنه يعتبر القرض ربويا بالنظر الى قانون القرض و النقد و كل القوانين التي تأخذ بالفائدة عندما تكون الفائدة المتفق عليها تفوق الحد الأقصى من الفائدة المقررة قانونيا حيث تنص المادة 5 من التعليمية 03-09 على ما يلي : "تحدد البنوك بكل حرية معدلات الفائدة الدائنة و المدينة و كذا معدلات و مستوي العمولات المطبقة على العمليات المصرفية غير أنه يمكن بنك الجزائر أن يحدد معدل الفائدة الزائد و لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تتجاوز معدلات الفائدة الفعلية الإجمالية على القروض الموزعة من طرف البنوك و المؤسسات المالية معدل الفائدة الزائد ...".

أما الربا في الشريعة فهو كل زيادة على رأس مال أو مبلغ القرض اشترطت في مقابل أجل و هي ليست محددة بحد معين فهي محرمة سواء قلت أو كثرت و مصدر التحريم النص القرآني إذ يقول الله عز و جل في سورة البقرة الآية 275 " أحل الله البيع و حرم الربا " ، "يأبها الذين آمنوا اتقوا الله و دروا ما تبقي من الربا. " آية 281 سورة البقرة.

و أركان الربا عند جمهور الفقهاء ثلاثة : الزيادة على رأس المال و قياس الزيادة بالمدة الزمنية التي تم على أساسها التأجيل و التقييط و اشتراط هذه الزيادة في العقد.

فالفائدة الاتفاقية أو المشروطة في عقد القرض غير جائزة عند جمهور الفقهاء بل اعتبروا أن كل قرض يجر منفعة من الربا بينما يعتبر القرض الحسن الذي

لا يجر منفعة للمقترض من قبيل الصدقات و هذا الوصف وارد في القرآن الكريم في عدة آيات "من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا".

و تذهب البنوك الإسلامية كبديل للفوائد إلى اتباع آليات مختلفة كالمشاركة في الربح و الخسائر و المضاربة و عقود الاستصناع و المراجعة.

و تعد المراجعة هي البديل الاسلامي لتمويل الاحتياجات الاستهلاكية.

و التمويل بالمراجعة يهدف الى الربح المشروع الخالي من الفائدة الربوية إذ الربح في البيع مشروع إذ تضمنت سورة البقرة آية 275 "أحل الله البيع و حرم الربا".

و يعتبر الدكتور الشحات الجندي أنه: "من الخصائص الاقتصادية تغير الأسعار و اختلافها من وقت لآخر و تعتمد الشريعة على حرية المنافسة و الأسعار المشروعة التي لا يتضمنها غبن أو احتكار أو خداع"، فتكون الزيادة في السعر ربحا و يستدلون في ذلك الى آية رقم 29 من سورة النساء "يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا عن تجارة عن تراضي منكم"، و يعتبرون البيع بالمراجعة البديل الاسلامي للإقراض فهو جائز شرعا.

بينما يعتبر بعض الفقه عقد المراجعة غير جائز شرعا و يعتبرون الزيادة في ثمن السلعة المبيعة بسعر أعلى من سعرها النقدي ربا نسيئه هذا ما أورده الدكتور الزرقاء مبينا أدلة الذي يحرمون البيع بالمراجعة من القرآن بآيات التي تحرم الربا عموما "يأيها الذين آمنوا اتقوا الله و دروا ما تبقي من الربا " سورة البقرة.

و أدلتهم من المعقول بأن "هذه المعاملة لا يتوافر فيها عنصر الرضا حيث تقوم على استغلال حاجة المشتري الى السلعة و عدم قدرته على الوفاء و هذا ما يدخل تحت النهي عن أكل أموال الناس بالباطل".

و يرى أصحاب هذا الاتجاه عموما أن كل زيادة في ثمن السلعة المبيعة بسعر أعلى من سعرها النقدي زيادة لا يقابلها عوض ربا محرم.

و يذهب غالبية الفقه على أن البيع بالمراجعة جائز شرعا لما تحققه من مصلحة في تداول السلع و عدم انكماش التجارة و أدلتهم في ذلك من القرآن "إن الله أحل البيع و حرم الربا". و لكن يشترطون في ذلك أن يتوفر في عقد المراجعة شروط و هي:

- 1- أن يكون العقد مكتوبا و لعل الكتابة تحقق إعلام المقترض (أي المشتري).
- 2- أن يحدد الثمن بدقة بحيث تكون الأقساط معلومة للمشتري.
- 3- أن يكون الأجل معلوم.
- 4- أن يمتلك المصرف السلعة فيحوزها و يتحمل تبعة الهلاك قبل تسليمها للمشتري.
- 5- أن يضمن المصرف السلعة بعد البيع باعتباره بائعا فيتحمل تبعة الضمان.

و قد تضمن المؤتمر الثاني للمصارف الاسلامية "أنه يجب أن يتوافر في الصيغة الاستثمارية عنصران هما المخاطرة و الربح فيستحق المصرف الربح بصفته ضامنا للسلعة حيث يتحمل تبعة هلاك السلعة قبل بيعها و يتحمل تبعة رد العميل السلعة إذا لم تكن مطابقة للمواصفات المطلوبة أو لظهور عيب فيها .

و الصورة الغالبة التي تعتمدها البنوك في الجزائر بصدد القروض الاستهلاكية هي بيع المرابحة لأمر بالشراء تتمثل في طلب العميل أو المقترض من البنك أن يشتري له سلعة معينة بمواصفات محددة على أساس وعد منه بشراء تلك السلعة له مرابحة و ذلك بنسبة ربح متفق عليه محدد و يدفع الثمن بأقساط فيكون بمثابة بيع بالتقسيط.

أطرافه:

الأمر بالشراء : هو الراغب في الشراء (المقترض).

البنك : المشتري المقرض.

و البائع.

السبب في القرض المخصص:

لا شك أن السبب في عقد القرض المخصص هو اقتناء سلعة معينة و لا يمكن منح القرض الاستهلاكي وفقا للمرسوم التنفيذي 2015 الا في اطار ذلك.

و يفرض ذلك ترابط بين عقد القرض و البيع، و هذا لتفادي حصول المقرض على المبيع دون أن يتحصل على القرض فيصير المشتري هنا ملزم بدفع الثمن و هو غالبا غير قادر على ذلك.

كما أنه يجنب الترابط بين القرض و البيع أيضا حصول المشتري على القرض دون تمكنه من الحصول على السلعة مما يلزمه بدفع الفوائد دون الاستفادة من السلعة.

و يسعى المشرع في مرسوم 2015 إلى تحقيق نوعا ما هذا الترابط على النحو التالي:

أولا: بالنسبة للبائع:

المادة 1/12 : "لا تسري آثار عقد البيع إذا:

لم يعلم المقرض البائع بتخصيص القرض في أجل ثمانية (8) أيام عمل،
ابتداء من تاريخ تبليغ الموافقة على الحصول على القرض،
مارس المقرض حقه في العدول ضمن الأجر المحدد له.

و يبقى عقد البيع صحيحا إذا دفع المشتري نقدا المبلغ المستحق كله قبل انقضاء الثمانية (8) أيام المبينة أعلاه".

كما أن المادة 1/11 تضمنت عدم التزام البائع بتسليم أو تمويل السلعة إلا بعد إخطاره من طرف المشتري بتحصله على القرض.

ثانيا: بالنسبة للمقرض:

تنص المادة 10 على ما يلي: "لا يمكن اكتتاب أي التزام من طرف المشتري اتجاه البائع في إطار القرض الاستهلاكي ما لم يتحصل هذا الأخير على الموافقة المسبقة للقرض.

يجب أن يحدد عقد البيع إذا كان القرض يغطي جزئيا أو كليا مبلغ السلعة موضوع المعاملة".

و المادة 13: "لا يمكن أن يستلم البائع من المشتري أي دفع آخر في شكل من الأشكال و لا ايداع زيادة على الجزء من الثمن الذي وافق المشتري على دفعه نقدا ما لم يبرم العقد المتعلق بعملية القرض نهائيا.

عندما يمضي المشتري رخصة الاقتطاع من حساب بنكي أو بريدي، فإن صلاحيتها و الأخذ الفعلي بها تكون مرتبطة بعقد البيع، و في حالة دفع جزء من الثمن نقدا فإنه يجب على البائع أن يسلم المشتري وصل استلام بالدفع".

و تجدر الاشارة أيضا أن المشرع نص في المادة 09 من مرسوم 2015: "في حالة فسخ العقد من طرف البائع، فإنه يلتزم بتعويض المقرض بناء على طلب مكتوب مع وصل التزام عن المبلغ كله الذي دفعه له المشتري كتسبيق على السعر في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما، دون المساس بالأحكام المتعلقة بالتعويضات عن الاضرار إزاء المقرض طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما".

و تعد هذه المادة غامضة و لا تؤدي للحماية المطلوبة فالمفروض توسيع الحماية في هذا الاطار.

الجزاء:

الجزاء على تخلف أركان عقد القرض هو ما ورد في القواعد العامة من بطلان و قابلية للإبطال إذا توافرت شروط ذلك، فلم يتضمن مرسوم 2015 جزاء خاص و إن كانت المادة 12 منه تضمنت المادة 12 نصت على أن : "لا تسري آثار عقد البيع إذا :

لم يعلم المقرض البائع بتخصيص القرض في أجل ثمانية (8) أيام عمل، ابتداء من تاريخ تبليغ الموافقة على الحصول على القرض، مارس المقرض حقه في العدول ضمن الأجر المحدد له.

و يبقى عقد البيع صحيحا إذا دفع المشتري نقدا المبلغ المستحق كله قبل انقضاء الثمانية (8) أيام المبينة أعلاه".

فهل ذلك يتطلب بطلان أم انفساخ أم إلغاء كما وردت في النصوص القانونية في تشريعات مختلفة ،على أن الالغاء هو أكثر موافقة في حالة ترابط العقدين و زوال عقد البيع لعدم الحصول على قرض أو التراجع و لكن المشرع اكتفى ب "لا تسري"...

كما أن قانون حماية المستهلك تضمن عقوبات جزائية لأنه غالبا ما ينطوي فعل المتدخل على غش كما في حالة الاشهار التضليلي، و لكن في جميع هذه الحالات أصبحت التشريعات تسعى إلى الجزاء الفعال لأن توقيع غرامة بسيطة على المخالف كما ورد مثلا في عدة نصوص و في قانون حماية المستهلك ،لا يعد جزاء فعال بل يعتبر أحيانا نوعا من الخطأ المربح لهذا تذهب بعض التشريعات الى فرض غرامة مالية مرتفعة تصل الى 300.000

يورو على كل من يخالف ما ورد من حماية ضمن نصوص القرض الاستهلاكي بل تفرض عقوبات تكميلية متعددة كالمنع من مزاولة النشاط التجاري لمدة خمس 5 سنوات، بينما لم يتعرض المشرع لأي جزاء خاص بل تذهب معظم التشريعات الى حرمان المؤسسة المالية من الحق في الفوائد في حالة الاخلال بالتزاماتها اتجاه المقرض ، كما تبقى بعض التشريعات حق التراجع قائما فيما يتجاوز المدة القانونية وذلك في حالة إذا لم يمكن المقرض أو البائع، المقرض أو المشتري من ذلك.

كل هذا غير وارد في القانون الجزائري فيما عدا ما سبق ذكره بخصوص حماية المستهلك و القواعد العامة.

ويلاحظ أن مرسوم 2015 يفتقد الى الجزاء الفعال الذي يجبر الملزم على احترامه.

الدرس العاشر

آثار عقد القرض الاستهلاكي

باعتبار أن عقد القرض الاستهلاكي الوارد في المرسوم 2015 عقد مخصص لشراء سلعة فالأمر يتطلب التعرض لالتزامات البائع و التزامات المقرض و المقرض علما أن كل التزام يتحمله أحد المتعاقدين يكون حقا بالنسبة لمن تقرر الالتزام لمصلحته ، و ألاحظ أنه هذه الالتزامات بعضها وارد في القانون المدني و بعضها في قانون حماية المستهلك و بعضها في نصوص خاصة.

أولا: بالنسبة لالتزامات البائع:

لقد تعرضتم الى عقد البيع في السنة الثالثة فلن أتناول الالتزامات إلا باختصار و خاصة فيما يتطلب كحماية خاصة بالنظر لحماية المستهلك.

و لا شك أن التزام البائع بتنفيذ العقد بحسن نية الوارد في المادة 107 مدني يمكن تفعيله كلما اقتضت الأمور ذلك.

1- الالتزام بالتسليم: ينطبق على التزام البائع بالتسليم القواعد العامة المواد 281 مدني و ما يليها.

و قد تعرض المشرع في المرسوم 2015 المادة 11 منه على أن البائع لا يلتزم بتسليم السلعة موضوع العقد إلا بعد إخطاره من طرف المشتري بتحصله على القرض.

و لم يتعرض المشرع الى مسألة التأخر في التسليم ففي حالة تأخر البائع في تسليم السلعة لا يكون للمشتري المقرض إلا الرجوع وفقا للقواعد العامة و منها المطالبة بالتسليم كما يمكنه فسخ العقد و في هذه الحالة يكون البائع ملزم برد المبلغ الذي دفعه المشتري في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما وفقا للمادة 09 التاسعة من مرسوم 2015 و لكن يأخذ على المشرع عدم نصه على الجزاء في حالة تأخر البائع عن رد المبلغ المدفوع الى المشتري مع أن هذا الأخير يمكنه دفع قسط أو جزء من الثمن قبل التسليم بمجرد إبرام عقد القرض وفقا للمادة 13 من مرسوم 2015.

و تذهب بعض التشريعات الى إضافة مبالغ معينة يدفعها البائع كلما تأخر عن رد المبلغ المدفوع تصل الى 50% من المبلغ المدفوع إذا جاوز تأخر البائع ستون 60 يوما.

و الجزء بهذا الشكل يجعل البائع يحرص على عدم التأخير ومن الضروري ادراجه بنص خاص فاحترام القاعدة القانونية مرتبطة بفعالية الجزء حتما.

2- **الالتزام بضمان العيب الخفي:** لا شك أن القواعد العامة في ضمان العيب الخفي و بالتحديد المادة 379 مدني تنطبق و يشمل ضمان العيب ضمان الصفات التي تعهد البائع بوجودها وقت التسليم وكل عيب ينقص من قيمة المبيع، إذ تنص المادة 379 مدني على ما يلي:

"يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يشتمل المبيع على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسليم الى المشتري أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته، أو من الانتفاع به بحسب الغاية المقصودة منه حسبها هو مذكور بعقد البيع، أو حسبما يظهر من طبيعته أو استعماله. فيكون البائع ضامنا لهذه العيوب و لو لم يكن عالما بوجودها.

غير أن البائع لا يكون ضامنا للعيوب التي كان المشتري على علم بها وقت البيع، أو كان في استطاعته أن يطلع عليها لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي، إلا إذا أثبت المشتري أ، البائع أكد له خلو المبيع من تلك العيوب أو أنه أخفاها غشا عنه".

و تشمل هذه المادة العيب بمفهوم الافة التي لا نجدها في المبيع السليم الى جانب أمور أخرى اعتبرها المشرع بمثابة عيب مثل الصفات التي تعهد البائع بوجودها أو وجود خلل ينقص من القيمة أو من منفعة من الشيء وفقا للاتفاق و لا شك أن هذا لا يشكل عيبا بالمفهوم الدقيق أو الاصطلاحي للعيب و لكن المشرع أضفي عليه حكم العيب.

و لقد تضمنت المادة الثالثة (03) من قانون حماية المستهلك في تعريفها للمنتوج السليم ما يلي:

"منتوج سليم و نزيه و قابل للتسويق: منتوج خال من أي نقص و/أو عيب خفي يضمن عدم الأضرار بصحة و سلامة المستهلك و/أو مصالحه المادية و المعنوية".

و النص يشمل العيب و/أو النقص بينما النص الفرنسي لنفس المادة يتضمن défaut et/ou vice caché و أن عبارة défaut و هو الخلل و هذا الأصح إذ أن المنتجات الخطرة التي تشكل خطراً على صحة المستهلك و سلامته قد لا يكون فيها عيباً و لا نقصاً بل فقط خلل قد يظهر باستعمالها الذي يتطلب الحيلة إذ لم ينبه بها المشتري لحقه ضرر في جسمه و/أو ماله.

بينما يعرف المشرع في قانون حماية المستهلك المادة الثالثة (3) المنتج الخطير بأنه هو ذاته المنتج السليم و لا شك أن النص العربي يحتاج الى التدقيق و التعرض للخلل الموجود في المبيع و هذا ما تضمنته كل التشريعات باعتبار الخلل أعم من العيب فيشمل المبيع الخطر الذي لا يوجد فيه عيب كما يشمل المبيع المعيب أيضاً.

و يلاحظ أن النص الفرنسي لجميع المواد يتعرض ل défaut اي الخلل و ليس العيب vice.

أما الجزاء المترتب على الاخلال بهذا الالتزام فقد تضمنت المادة الثالثة (03) من قانون حماية المستهلك في تعريف الضمان على ما يلي:

"الضمان: التزام كل متدخل خلال فترة زمنية معينة، في حالة ظهور عيب بالمنتج، باستبدال هذا الأخير أو ارجاع ثمنه أو تصليح السلعة أو تعديل الخدمة على نفقته".

كما تعرض المشرع في المرسوم التنفيذي رقم 13-327 المؤرخ في 26 سبتمبر 2013 و المحدد لشروط و كفاءات وضع ضمان السلع و الخدمات حيز التنفيذ في المادة 12 على ما يلي:

"يجب أن يتم تنفيذ وجوب الضمان طبقاً للمادة 13 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 و المذكورة أعلاه، دون تحميل المستهلك أي مصاريف إضافية إما:

- بإصلاح السلعة أو إعادة مطابقة الخدمة،
- باستبدالها،
- برد ثمنها.

و في حالة العطب المتكرر، يجب أ، يستبدل المنتج موضوع الضمان أو يرد ثمنه".

و يلاحظ أن الضمان القانوني إلزامي و لا يجب أن يقل عن ستة (6) أشهر وفقا للمادة 16 من المرسوم المذكور أعلاه، و بالتالي لا يجوز الاتفاق على استبعاده على عكس ما هو وارد في المادة 384 مدني التي تجير الاتفاق على استبعاد الضمان أو انقاصه ، وبخصوص المستهلك نطبق النص الخاص حتما.

3-الالتزام بالمطابقة: يمكن تقسيم المطابقة الى مطابقة شخصية و موضوعية.

تتمثل المطابقة الشخصية في ما تم الاتفاق عليه في العقد و هذا ما تضمنته المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي 13-327 على أنه يجب تسليم سلعة أو خدمة مطابقة لعقد البيع.

كما تشمل المطابقة الموضوعية الى ما يجب أن تكون عليه السلعة بالنظر الى الانتظار المشروع للمستهلك فقد نصت المادة 11/1 من قانون حماية المستهلك على ما يلي: " يجب أن يلبي كل منتج معروض للاستهلاك الرغبات المشروعة للمستهلك من حيث طبيعته وصفه ومنشئه و مميزاته الاساسية وتركيبته ونسبة مقوماته اللازمة وهويته وكمياته وقابليته للاستعمال والأخطار الناجمة عن استعماله. "

كما نصت المادة 10 من المرسوم التنفيذي 13-327 على ما يلي:

"يجب أ، يكون المنتج موضوع الضمان صالحا للاستعمال المخصص له، و عند الاقتضاء:

- يوافق الوصف الذي يقدمه المتدخل و حائزا كل الخصائص التي يقدمها هذا المتدخل للمستهلك في شكل عينة أو نموذج.
- يقدم الخصائص التي يجوز المستهلك أن يتوقعها بصفة مشروعة أ، يتوقعها بصفة مشروعة، و التي أعلنها المتدخل أو ممثله علنا و لا سيما عن طريق الإشهار أو الرسم.
- يتوفر على جميع الخصائص المنصوص عليها في التنظيم المعمول به".

و يلاحظ أن المشرع في المرسوم التنفيذي رقم 13-327 يتعرض للمطابقة عموما و يشمل ذلك خلو المبيع من العيب أيضا و هذا ما شملته المادة 04 منه .

فلا شك أن توافر المنتج أو المبيع على الخصائص التي يتوقعها المستهلك عادة و بصفة مشروعة تشمل حتما الى جانب المواصفات العقدية خلو المبيع من العيوب.

لهذا تعرضت التوجيهات الأوروبية بخصوص ضمان السلع و الخدمات إلى المطابقة العقدية و خلو المبيع من العيوب ضمن التزام وحيد هو المطابقة يشمل المطابقة لأوصاف العقدية و خلو المنتج من العيب.

4 - الالتزام بالسلامة: و المقصود بذلك أن المنتج يجب أن لا يحقق ضررا بالمستهلك سواء بصحته و أمنه و مصالحه عموما و قد وضع المشرع عنوان في الفصل الثاني من قانون حماية المستهلك الزامية أمن المنتجات و تناولت المادة التاسعة (09) منه ما يلي:

"يجب أن تكون المنتجات الموضوعة للاستهلاك مضمونة و تتوفر على الأمن بالنظر الى الاستعمال المشروع المنتظر منها، وأن لا تلحق ضررا بصحة المستهلك و أمنه و مصالحه، و ذلك ضمن الشروط العادية للاستعمال أو الشروط الأخرى الممكن توقعها من قبل المتدخلين".

فقد يكون المنتج معيبا يلحق ضررا بالمستهلك في جسمه و مصالحه و لكن قد يخلو من العيب و لكن باستعماله يشكل خطورة تلحق ضررا بالمستهلك، فإذا لم يكن الضرر سببه الاستعمال السيء للمنتج و لكن عدم توافر في المنتج الأمن بالنظر الى الاستعمال المشروع المنتظر منه أو من المعقول توقعه، فتقوم مسؤولية المتدخل و يتعين على كل متدخل احترام الزامية أمن المنتج إذ قد يرجع عدم الأمن الى المنتج ذاته و هذا ما أورده المشرع في المادة 1/10 قانون حماية المستهلك.

و ألاحظ ان الالتزام بالسلامة مطلوب في مواجهة الناس كافة و ليس المستهلك فقط بل دون تفرقة بين المتعاقد الذي يرفع دعوى المسؤولية العقدية و غير المتعاقد الذي يمكنه الرجوع على المنتج بدعوى المسؤولية التقصيرية و هذا ما تضمنته المادة 140 مكرر مدني و لو أن المشرع قصرها في القانون المدني عن الضرر الناتج عن العيب و ألزم بها المنتج دون غيره إذ تنص المادة 140 مكرر على ما يلي:

"(القانون رقم 05-10 المؤرخ في 20 يونيو 2005). يكون المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عيب في منتج حتى و لو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدية.

يعتبر منتوجا كل مال منقول و لو كان متصلا بعقار، لاسيما المنتوج الزراعي و المنتوج الصناعي و تربية الحيوانات و الصناعة الغذائية و الصيد البري و البحري و الطاقة الكهربائية".

مع الملاحظة أيضا أن المادة 4 من المرسوم التنفيذي 2015 المذكورة سابقا تحدد فئة المتعاملين الذين تكون منتجاتهم مؤهلة للقرض.

5- الالتزام بضمان الخدمة ما بعد البيع : و يشمل هذا الالتزام ضمان صيانة و تصليح المنتوج و قد تعرض المشرع في المادة 16 من قانون حماية المستهلك لالتزام المتدخل بالخدمة ما بعد البيع و ذلك في الحالتين التاليتين:

1/ بعد انقضاء فترة الضمان: و ذلك لأن اصلاح المنتوج في فترة الضمان يندمج في اطار الضمان القانوني الذي يكون اجباري و بدون مقابل و هذا ما أورده المشرع في المادة 4/13 كما يلي:

" يستفيد المستهلك من تنفيذ الضمان المنصوص عليه أعلاه دون أعباء اضافية".

2/ في الحالات التي لا يمكن أن يلعب الضمان دوره سواء لسقوط المدة أو أن يكون الخلل في المنتوج سببه خطأ من المشتري أو عدم اتباع الاجراءات القانونية المطلوبة أو الخاصة بكيفية الرجوع بالضمان ... الخ ، أي في جميع الحالات التي لا يمكن الرجوع بالضمان القانوني فيجب أن يوفر البائع للمستهلك كيفية اصلاح و صيانة المنتوج وهي من الالتزامات القائمة على عاتق المتدخل.